

1500060-55.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... dos antecedentes criminais do acusado, relativos a tráfico inclusive, seja por conta da clara dedicação às atividades criminosas, uma vez que desde 2013 o acusado envolve-se em ocorrências relativas a tráfico.

Sendo assim, a pena fica em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e antecedentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500060-55.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500060-55.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011441/2022 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 22422138 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2011441 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LEANDRO PEREIRA DA SILVA imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Narra a denúncia que no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 06 horas, na Rua José Castanheira Pedrosa, nº 50, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Andradina, LEANDRO PEREIRA DA SILVA, vulgo "Tortinho", qualificado às fls. 12, 50 e 60/61 dos presentes autos, tinha em depósito, para fins de tráfico: a) 32 porções de cocaína, na forma de pedra ("crack"), com peso aproximado de 9,35g; e b) 01 porções de "maconha", com peso aproximado de 1,25g, (cf. autos de constatação provisórios de fls.40/44 e 45/48), substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 em decisão de fls.166/167. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.144/160.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, reiterou os termos da resposta à acusação, no sentido de ser o acusado usuário de drogas e não traficante, requerendo aplicação do princípio da insignificância pela diminuta quantidade encontrada, por ausência de ofensividade

da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. Requereu, assim, absolvição por ausência de tipicidade e, subsidiariamente, aplicação de pena alternativa de tratamento para usuário de drogas, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, e fixação da pena em patamar mínimo.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/03, boletim de ocorrência de fls.04/06, termo de depoimento de fls.08/11, termo de interrogatório de fl.12, autos de exibição e apreensão de fls.38/39, laudos periciais de fls.40/48, fotografias de fls. 62, 74/77, 80 e 163), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

O policial civil e testemunha Marcell Das Neves Rafael afirmou que estavam apurando denúncias anônimas contra o Leandro, vulto Tortinho, que já era bastante conhecido pela prática de tráfico, sendo que já tinha sido preso em flagrante por quatro vezes em razão desse delito. No dia dos fatos foram cumprir o mandado de busca e se dirigiram diretamente ao quarto do acusado. Notou que ele estava com algo na mão e que tentava engolir. Era uma pedra grande de crack. Embaixo do tanque havia mais crack. No quarto também localizaram mais porções de crack. Na cozinha, uma porção média de maconha e na carteira dele 688,00. Disse não ter localizado no local um cachimbo para uso do crack.

A testemunha e policial civil Jota Teodoro Coimbra prestou declarações no mesmo sentido, sem acréscimos ou divergências dignas de nota.

Gabriela Letícia de Oliveira Andrade Silva, esposa do réu, prestou declarações sem prestar compromisso, e disse que no dia anterior aos fatos o réu havia recebido R\$ 1.152,00 por trabalho com reciclagem. Acordou de madrugada para beber água e notou que o réu não estava, então foi até o fumódromo, onde ele costumava ficar usando drogas. Foi com sua bebêzinha. Depois, o acusado continuou usando drogas na varanda, sendo que a polícia chegou e o prendeu. No local havia um cachimbo de crack para uso do acusado.

Interrogado, o réu negou a traficância, dizendo que havia comprado R\$ 300,00 em crack para seu consumo. Trabalha com reciclagem, e naquela noite ficou na varanda de sua casa usando drogas pela madrugada toda, até a chegada da polícia. Não sabe dizer por que sempre é preso pela polícia por tráfico, talvez seja por conta de algum vizinho que lhe denuncie indevidamente.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese, houve a apreensão de 32 porções de cocaína em forma de crack com massa líquida de 9,35g. A quantidade que em um primeiro momento pode não parecer tão relevante, mostra-se totalmente suficiente para o tráfico, especialmente considerando-se as proporções da cidade de Andradina (com população atual estimada em cerca de 57 mil habitantes). Veja-se, apenas a título de argumentação, que a pedra de crack para consumo imediato em cachimbo tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). Ou seja, a quantidade encontrada seria suficiente para mais de 46 doses da droga, totalmente passível de distribuição também.

Quanto às circunstâncias da prisão, certo que os policiais relataram de forma firme e consistente, com suporte inclusive em fotografias, que as drogas estavam espalhadas em diversos cômodos e locais da casa (inclusive em área externa - fls.

74/77), a infirmar a versão de que se trataria de entorpecente destinado exclusivamente a uso pessoal do réu. Caso contrário, bastaria o réu concentrar toda a droga para seu uso em local único, reservado dentro de sua casa – não faria qualquer sentido espalhar a droga em diversos cômodos, o que somente dificultaria ao réu localizá-los quando pretendesse usar a droga.

No que toca aos antecedentes do acusado, verifico que ostenta condenação definitiva pelo mesmo crime (fl. 88), além de inúmeras ocorrências em que sempre encontrava-se em atitude deveras suspeita e limítrofe, tendo sido por algumas vezes condenado em primeiro grau e absolvido em grau de recurso. Ao que parece, o acusado ostenta um *modus operandi* próprio, no sentido de portar quantidade de drogas que indicariam em um primeiro momento mero uso pessoal, mas com finalidade efetiva de venda.

Confirmam-se os documentos de fls. 16/34, os quais indicam de forma detalhada tal modo de agir, sempre em situações suspeitas e em fuga da polícia, civil e militar. Também de se notar que há registro recente indicando o réu e sua residência como ponto de venda de crack, conforme fl. 35, inclusive com detalhamento de que o acusado valeria-se de um "olheiro" de prenome Thiago.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário.

Corroborando tal raciocínio: "a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

E, como dito, também é usual que traficantes mantenham consigo, ou mesmo apenas próximo de si, apenas parte droga (só as porções para venda imediata; em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo). De forma estratégica, ocultam o restante em outro local, evitando uma grande apreensão, como que pré-estabelecendo a alegação de que seriam meros usuários e de que não sabem a procedência dos entorpecentes encontrados. As circunstâncias do caso indicam que o réu já se valeu de tal expediente em outras oportunidades e que é efetivamente comerciante (além de provável usuário).

Anoto que não faria sentido as polícias militar e civil da Comarca de Andradina "perseguirem" por quase uma década (a primeira ocorrência é de maio de 2013 – fl. 16) um simples usuário de crack, sem qualquer motivo idôneo e relevante para tanto. E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Portanto, em que pese a documentação indicando que o acusado teria recebido remuneração em dia anterior aos fatos, reputo que o conjunto de provas lhe é amplamente desfavorável, também não servindo como fator escusatório a simples apresentação do cachimbo de fl. 163, por não infirmar a versão acusatória, bastante consistente, de forma cabal.

Quanto à versão do réu, percebe-se, que incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, não apontando motivos aptos a motivar a desconsideração prova oral colhida ao longo da instrução. Em suma, a versão escusatória não encontra respaldo nos autos, revestindo-se inclusive de contradições, já que a esposa do réu disse que foi buscá-lo no fumódromo e este disse que teria passado a madrugada na varanda de sua casa usando drogas. Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de

tráfico de drogas é procedente, devendo o réu receber a correspondente sanção penal.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima $\frac{1}{8}$ sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($\frac{1}{6}$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $\frac{1}{6}$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de

pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico. Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP – 5ª Turma – julgado em 11/02/2020), verbis:

“2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais”. E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO – 6ª Turma – julgado em 24/09/2019): “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base”.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, a natureza da droga recomenda a exasperação da pena-base em 1/8, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito). A droga que o réu tinha em seu poder para fins de tráfico, crack, é de alto poder viciante e destrutivo, que atualmente acarreta grave problema social em nosso país. Não seria isonômico aplicar àquele que trafica substância de menor nocividade o mesmo patamar para o traficante de drogas mais "pesadas". Cabe a exasperação, portanto, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Observo também que o acusado ostenta antecedentes criminais por tráfico de drogas, conforme fl. 88. Anoto desde logo que as condenações já depuradas pela reincidência valem como antecedentes criminais ao menos por mais 5 anos após a depuração da reincidência ou pelo prazo prescricional aplicável

à pena aplicada, tendo em vista toda a construção do sistema penal brasileiro sobre a dicotomia reincidência e antecedentes). Tal fator também ensejará exasperação em 1/8.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (5 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 10 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta

melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP – 5ª Turma – julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO – 6ª Turma – julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (5 anos) o montante de 2 anos e 6 meses de reclusão, montante equivalente a 2/8 de 10 anos (intervalo de pena estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime) e estabeleço a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, seja por conta dos antecedentes criminais do acusado, relativos a tráfico inclusive, seja por conta da clara dedicação às atividades criminosas, uma vez que desde 2013 o acusado envolve-se em ocorrências relativas a tráfico.

Sendo assim, a pena fica em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e antecedentes deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO LEANDRO PEREIRA DA SILVA, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e foi condenado a pena relativamente alta.

Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que seja posto em liberdade. Anoto, ainda, que ostenta antecedente criminal por tráfico, havendo risco de reiteração, portanto.

Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento. Vale a presente como reavaliação da preventiva, na forma do 316, parágrafo único, do CPP.

À míngua de cálculo sobre o lapso de pena cumprida e dados sobre o comportamento do acusado, eventual juízo sobre a progressão de pena deve ser efetuado pelo juízo das execuções.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad) ou sua destruição caso inservíveis, na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 29 de abril de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)